

1500430-78.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE DA FONSECA TAVARES

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... do flagrante para restar configurado o crime de tráfico de entorpecente.

Isso porque o crime de tráfico é de perigo abstrato, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: "o tráfico ilícito de entorpecentes... é um crime de perigo (há uma probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado) abstrato (independe de prova dessa probabilidade de dano, pois presumida pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

2ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Mirassol-SP - cep 15130-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500430-78.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500430-78.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2065573/2022 - DEL.POL.MIRASSOL, 23488362 - DEL.POL.MIRASSOL, 814/22/413 - DEL.POL.MIRASSOL, 2065573 - DEL.POL.MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SEBASTIAO HENRIQUE DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. ANDRE DA FONSECA TAVARES

Vistos.

SEBASTIÃO HENRIQUE DE LIMA, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque segundo a denúncia, no dia 09 de março de 2022, por volta das 10hs, na Rua Jaime Romero Serrano, nº 2665, Centro deste Município e Comarca de Mirassol, o acusado mantinha em depósito e guardava 377 (trezentos e setenta e sete) porções de Cannabis Sativa L ("maconha"), cuja parcela encaminhada à realização de laudo constou peso líquido de 18 (dezoito) quilogramas, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar para fins de tráfico ilícito, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, laudo de constatação de fls. 16/18, exame químico-toxicológico às fls. 120/122.

O acusado foi citado, apresentou resposta à acusação e a denúncia foi recebida no

dia 06 de abril de 2022. Houve audiência de instrução e apresentação de memoriais pelo Ministério Público e pela Defesa do acusado. É o relatório do essencial.

#### FUNDAMENTO E DECIDO.

Em primeiro lugar afasto a preliminar de nulidade de justa causa a conduta policial, por ter iniciado a diligência por meio de denúncia anônima, não haver prévia investigação antes do ingresso forçado no imóvel e sem autorização judicial para investigar e violar o imóvel.

Os policiais tinham fundadas razões que indicavam que no local estava sendo cometido um crime, o que motivou a entrada na casa em construção, que aliás nem era de propriedade do réu, mas sim local onde prestava serviço. Os policiais tinham informação de uma pessoa, que anteriormente se dirigiu à delegacia de polícia e precisou com detalhes a guarda do entorpecente, de quem o estaria guardando, inclusive informando nome e características físicas do réu.

Dessa forma, a situação flagrancial é perfeita, os policiais diligenciavam diante de fundadas suspeitas a fim de verificar a informação apresentada na delegacia de polícia, não agiram sob intuição, mas sim direcionados por informações precisas.

Nesse sentido: "O ingresso regular da polícia no domicílio, sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, para que seja válido, necessita que haja fundadas razões (justa causa) que sinalizem a ocorrência de crime no interior da residência. A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agente, embora pudesse autorizar abordagem policial em via pública para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação judicial." STJ. 6ª Turma. REsp 1574681-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 20/4/2017 (Info 606).

Ainda, decisão recente da Ministra Rosa Weber afasta essa necessidade de mandado para eventual cumprimento de diligência: "A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado." (RHC 213852 AgR, Relator(a) ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVUL31/-05-2022 PUBLIC 01-06-2022).

Afastada a preliminar, transcrevo o tipo penal indicado na denúncia. Diz o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

A materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls.01/02), pelos Termos de Depoimentos (fls.03, 04), pelo Auto de Interrogatório (fls.05), pela Nota de Culpa (fls.10), pelo Boletim de Ocorrência (fls.06/07), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls.08/09), pelas fotografias (fls.21/22), pelo ofício de encaminhamento de preso (fls.15), pelo Laudo Pericial (fls.16/18, 120/122), pelo Relatório Final (fls.123/124), bem como pela prova oral produzida. Passo à análise da autoria.

O policial militar NIVALDO contou na delegacia de polícia que "faz parte da equipe 55 do BAEP e estava de serviço junto do policial militar Talisdaltro e receberam uma informação que no Bairro Vale do Sol, numa casa em construção uma pessoa conhecido por Sebastião estava guardando uma carregamento de drogas; Que chegando no local avistaram Sebastião em frente a casa, ele ao ver a viatura passou a entrar na residência devagar, tentando despistar os policiais, porém foi chamado e ao retornar e inquirido a respeito das drogas que estava em sua casa, declinou "perdi o B.O. está aí dentro" ao ser localizada uma grande quantidade de drogas aparentando ser maconha pelas características de cor cheiro, o autuado declinou que não mais iria se manifestar, passando a ficar calado; Que não havendo dúvidas quanto a pratica delitativa perpetrada pelo autuado, foi lhe dado voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, sendo conduzido a unidade policial, não sendo necessário o uso de algemas. Informa que foram apreendidos um total de trezentos e setenta e sete tabletes de maconha". Em juízo confirmou seu depoimento, de forma

coerente e harmônica, dizendo ainda que “o réu também foi mencionado como 'véio' pela pessoa que deu notícia. O réu falou que a casa era dele, estava construindo-a. O réu tentou entrar na casa na segunda vez que a viatura passou, mas o chamaram”. O policial militar TALISDALTRO na delegacia de polícia confirmou o depoimento de seu colega de farda Nivaldo. Em juízo confirmou seu depoimento, de forma coerente e harmônica, dizendo ainda que “não se recorda se o réu já tinha passagem por tráfico. O réu admitiu que tinha a droga, mas não deu detalhes da procedência e destino. Não se lembra se o réu mencionou para quem estava guardando a droga. Era na parte da manhã, mais cedo. Quando a viatura passou a primeira vez, o réu estava para dentro, portão fechado. Na segunda vez, o réu tinha aberto o portão e estava na calçada. O réu tentou entrar na casa na segunda vez que a viatura passou, mas o chamaram. A construção do local estava bem “crua”, sem reboco. A pessoa que deu a notícia não quis se identificar, dizendo que havia um senhor, de nome Sebastião, em uma casa em construção, praticando o tráfico”.

O réu SEBASTIÃO, na delegacia de polícia disse que “nega as acusações dos policiais militares e declina que é pedreiro e estava em uma obra em que trabalha no Bairro Vale do Sol, quando foi abordado por policiais militares no seu interior, onde policiais militares declinaram que acharam uma grande quantidade de drogas, porém o autuado não os presenciou acharem; não sabe declinar a quem pertence e nega que estava guardando as drogas para alguma pessoa. Declina que não foi agredido quando de sua prisão, não estando machucado”. Em Juízo, disse que NÃO é verdadeira a acusação, falou que “lhe abordaram e o acusaram de tráfico. A casa não era sua, mas prestava serviço. Não sabia que tinha droga na casa. Acha que foi acusado porque tinha passagem. Não se recorda do nome do cliente dono da casa, apesar de ter ficado 8 meses trabalhando ali. As demais pessoas no local não foram revistadas e nem puxada a ficha. Não pediram autorização para entrar”.

Portanto, diante do que restou apurado, de rigor a procedência da ação penal. O réu negou o crime, mas não apresentou nada que poderia justificar falsa acusação dos policiais contra si. Não soube justificar a guarda do entorpecente, apenas dizendo que não era seu e apenas prestava serviço no local, porém não soube informar o nome de seu empregador, engenheiro ou qualquer pessoa responsável pela obra, mesmo afirmando que ficou oito meses trabalhando no local. Já os policiais foram firmes e uníssonos em seus depoimentos. Deram a mesma versão em juízo quando do auto de prisão em flagrante. Não há, ainda, qualquer razão para se duvidar do relato dos agentes públicos, que não teriam motivos para acusar o réu injustamente, sendo seus testemunhos válidos, com o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos, sendo inquestionáveis, até que se prove o contrário, por gozarem de fé pública e quando corroborado com os outros elementos de prova.

Os policiais contaram que foram informados de que o réu estaria guardando um carregamento de drogas, dessa forma ele teria sido abordado quando estava ingressando à residência e que ele mesmo admitiu a existência de drogas no interior do imóvel, o que confirmou a denúncia recebida pelos policiais. O exame químico-toxicológico (fls.120/122) realizado nos entorpecentes encontrados em poder do réu resultou em positivo para TETRAHIDROCANABINOL (THC), substância de uso proscrito no Brasil. Observo que a quantidade da droga e sua forma de acondicionamento demonstra a finalidade diversa do simples uso. Fica afastada, portanto, a tese para uso próprio, sendo irrelevante estar provada a existência de trabalho lícito, visto que a mercancia da droga pode coexistir com ele.

Importante registrar também que é desnecessária a demonstração da comercialização da droga no momento do flagrante para restar configurado o crime de tráfico de entorpecente.

Isso porque o crime de tráfico é de perigo abstrato, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “o tráfico ilícito de entorpecentes... é um crime de perigo (há uma probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado) abstrato (independe de prova dessa probabilidade de dano, pois presumida pelo legislador na construção do tipo)... não se permite ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram à sociedade não ser conveniente à sociedade a circulação de determinadas tipos de drogas”. (Leis penais e processuais penais

comentadas, 2ª ed. 2007, Editora Revista dos Tribunais, p. 314/315). Ou seja, é punida a conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, portanto, não há necessidade de efetiva prática do ato de comércio da substância entorpecente com a finalidade de venda.

Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - TESES DEFENSIVAS: I) DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. II) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. III) REESTRUTURAÇÃO DA PENA. IV) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AS TESES DEFENSIVAS NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Demonstrado que o réu guardava a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação por tráfico. 2. As provas produzidas ao longo da instrução são suficientes para ensejar a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo como acolher a pretendida desclassificação da conduta para a de uso próprio. 3. O tráfico de drogas é delito de perigo abstrato e presumido, criado com o fim de tutelar a saúde e segurança pública, não se restringindo à esfera pessoal do agente, ao contrário, atinge toda a coletividade, vez que estimula outras condutas criminosas, aumentando sobremaneira a violência em nossa sociedade, motivo pelo qual não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância. 4. Inviável o acolhimento da pretendida reestruturação da pena, de acordo com o princípio da proporcionalidade, tendo em vista que já fixada no patamar mínimo legal, após análise esmerada de cada um dos moduladores descritos no art. 59, do CP. 5. Impossível prosperar o pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea no caso em tela, eis que o acusado, na fase policial, silenciou-se e, em juízo, apesar de admitir que a droga era de sua propriedade, alegou que seria destinada ao uso e não ao tráfico, crime este pelo qual restou condenado... O tráfico de drogas é delito de perigo abstrato e presumido, criado com o fim de tutelar a saúde e segurança pública (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Esse delito não se restringe à esfera pessoal do agente, ao contrário, atinge toda a coletividade, vez que estimula outras condutas criminosas, aumentando sobremaneira a violência em nossa sociedade. Daí porque não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância." (Apelação Criminal 1.0480.11.006978-2/001; 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, RELATOR WALTER LUIZ DE MELO; j. 28/08/2012).

Ainda: "TÓXICOS - TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIDADE - PROVA SUFICIENTE - INSIGNIFICÂNCIA - NÃO APLICAÇÃO - NEGATIVA DA AUTORIA ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - CREDIBILIDADE - COMÉRCIO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS - REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A SUA APLICAÇÃO - FRAÇÃO - MANUTENÇÃO - REGIME PRISIONAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SUBSTITUIÇÃO DO ART. 44 DO CPB - CABIMENTO NO CASO CONCRETO. - Se, apesar de o réu negar a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, as provas são aptas a comprovar os fatos havidos na denúncia, correta é a condenação nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06. - A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para tornar a conduta atípica, uma vez que o delito de tráfico, enquanto delito de perigo abstrato, apresenta grande lesividade à saúde e à incolumidade pública, o que não pode ser graduado somente pela quantidade de entorpecente apreendida. - Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes e seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé. - Para a caracterização do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06, crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga pelo agente, não exigindo a consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente. - É cabível a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos se o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa. - A fração de redução de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, deve ser fixada de acordo com as regras do art. 59 do CPB daquela norma antidrogas. - Adotando o novo entendimento disposto quando do julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, cabível é a concessão do regime prisional diverso do fechado nos casos de tráfico privilegiado. - Preenchidos os requisitos legais, cabe

conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, mesmo no caso de tráfico de entorpecentes.". (Apelação criminal nº 1.0079.10.610239-9/001, 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, RELATOR CATTÁ PRETA, j. 04/09/2012).

Diante de todo o exposto, considero que o réu praticou o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, lembrando que a pena mínima nesse caso é de 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa.

Na aplicação da pena, sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do art. 62 da Lei de Drogas, verifico que o réu possui anotações (fls.23/24), porém serão consideradas na segunda fase da dosimetria, assim, fixo a pena no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica (Fls. 23 - Processo 0004267-57.2013.8.26.0358), pelo que aumento a pena em 1/3, considerando a equiparação do delito de tráfico de entorpecentes a crime hediondo prevista na própria Constituição, artigo 5º, inciso XLIII, nesse sentido: "Na segunda fase, em razão da agravante da reincidência (condenação por dois roubos triplamente majorados, estupro e atentado violento ao pudor páginas 42/43, cujas penas ainda estavam sendo cumpridas página 54), as penas foram parcimoniosamente aumentadas em 1/6. No esteio do inconformismo do Ministério Público, de rigor o acréscimo em 1/3, visto que se trata de reincidência específica e por crime hediondo...." (Apelação Criminal nº 1501228-73.2021.8.26.0559, 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo Minas Gerais, RELATOR PINHEIRO FRANCO, j.30/05/2022).

Dessa forma fixo a pena na segunda fase em 07 (sete) anos, 09 meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, impossível aplicar a redutora do §4º do art. 33 da lei de drogas, pela reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que torno a pena acima definitiva.

O regime carcerário será inicialmente o FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, considerando também a reincidência. Cada dia multa deverá ser calculado no mínimo legal (um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente), diante da ausência de elementos quanto à situação econômica do réu, e o valor deverá ser corrigido no momento da execução.

O réu não tem direito a benefícios que substituem a pena privativa de liberdade, principalmente por não preencher os requisitos subjetivos do artigo 44, e do artigo 77, ambos do Código Penal. Além disso, aplica-se o disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06: "Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos".

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada a natureza difusa do ofendido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e assim CONDENO o réu SEBASTIÃO HENRIQUE DE LIMA, como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a cumprir a pena de 07 (sete) anos, 09 meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, em regime inicial FECHADO. A pena de multa deverá ser calculada no mínimo legal, conforme fundamentação acima, a ser atualizada pelos índices de correção monetária no momento da execução, nos termos do artigo 49, § 2º do Código Penal.

A prisão cautelar do réu deve ser mantida. A quantidade de entorpecentes apreendida em sua posse demonstra que seria impossível ficar em liberdade sem prejudicar a ordem pública, sendo reincidente específico. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra.

Por fim, quanto ao entorpecente apreendido (fls.08/09), o Juízo do Plantão Judiciário já determinou sua incineração (fls.62) nos termos do Provimento CG 45/2018 e do artigo 524-A NSCGJ. Cumpra-se.

Custas "ex lege". Ao defensor nomeado, arbitro honorários nos termos do convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil - SP em vigor. Expeça-se certidão.

P.I.C. Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Mirassol, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA